

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2478/2532

บริษัท อี ริกสัน เทเลโฟนคอร์ปอเรชั่น
ฟาร์อีสท์ จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 70 ทวิ, มาตรา 76 ทวิ

โจทก์มิได้มีอำนาจทั่วไปในการเจรจาและตกลงทำสัญญาต่าง ๆ แทนบริษัท แอลเอ็มอีริกสัน จำกัด บริษัทต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนเป็นปกติวิสัย โจทก์จึงไม่เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัท แอลเอ็มอีริกสัน จำกัด ตามความ ตกลงว่าด้วยอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้น การเก็บ ภาษีซ้อน โจทก์จึงไม่มีภาระที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล แทนบริษัทแอลเอ็มอีริกสัน จำกัด.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2520 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มจากโจทก์ตามแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลและเงินเพิ่มที่ต.9/1041/2/00744-49 รวม 6 ฉบับ เรียกเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลและเงินเพิ่มจากโจทก์สำหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2510 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2512 รวมเป็นเงิน 1,640,804.17 บาทโดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อให้แก่บริษัทแอล เอ็ม อีริกสัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต่าง

ประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้รับเงินและผลกำไรในประเทศไทย โจทก์ในฐานะตัวแทนจึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นและจะต้องคำนวณเงินภาษีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดรายรับกับจะต้องเสียภาษีจากการจำหน่ายกำไร โจทก์ไม่เห็นด้วย ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การประเมินของเจ้าพนักงานชอบแล้วจึงให้ยกอุทธรณ์ โจทก์เห็นว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่ม การประเมินของเจ้าพนักงานจำเลยมิชอบด้วยกฎหมาย เพราะโจทก์มิได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะลูกจ้าง ผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อแทนบริษัทแอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด อันเป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยแต่อย่างใด บริษัทดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศสวีเดนตามความหมายแห่ง "ความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน" และมีได้มีสถานประกอบการถาวรในราชอาณาจักรไทย โจทก์มิได้กระทำการอย่างใดที่ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด ขอให้พิพากษาเพิกถอนแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่ม และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลย และให้งดหรือเบี่ยงปรับและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์เป็นตัวแทนบริษัทแอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายประเทศสวีเดนทำการติดต่อในการจัดซื้อและส่งมอบเครื่องชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นเหตุให้บริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย โจทก์จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกับเสียภาษีเงินได้ในจำนวนเงินที่จำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยให้แก่บริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด และเนื่องจากบริษัทโจทก์เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด ในประเทศไทยจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการยกเว้นภาษี

ตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน แต่โจทก์มิได้ยื่นรายการและเสียภาษีไว้ เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยจึงได้ประเมินเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มเรียกเก็บจากโจทก์เป็นเงินรวม 1,640,804.17 บาท โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการประเมินถูกต้องแล้ว ทั้งโจทก์มิได้อุทธรณ์ขอให้งดหรือลดเงินเพิ่มต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงไม่มีสิทธิยกประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินเพิ่ม

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสวีเดน และมีสำนักงานสาขาในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2512 บริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวีเดน ได้ติดต่อและทำสัญญาขายเครื่องชุมสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตามเอกสารหมายเลข 10 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2520 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มให้โจทก์ชำระเป็นเงิน 1,640,804.17 บาท โดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้ทำการแทนหรือทำการติดต่อให้แก่บริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด เป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้รับ

เงินได้และผลกำไรในประเทศไทย โจทก์อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์

ปัญหาในชั้นฎีกามีว่า โจทก์เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทแอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด หรือไม่ โดยคู่ความยอมรับกันว่าหากโจทก์ไม่เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทดังกล่าว โจทก์ก็ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรที่พิพาทกันในคดีนี้ เพราะบริษัทดังกล่าวจะได้รับยกเว้นภาษีอากรตามความตกลงระหว่างประเทศไทย กับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเอกสารหมายเลข 4 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อ 3(1) แห่งความตกลงดังกล่าวระบุว่า กำไรของวิสาหกิจของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่งให้เสียภาษีเฉพาะแต่ในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายนั้นเท่านั้นเว้นไว้แต่ว่าวิสาหกิจนั้นกระทำธุรกิจภายในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผ่านทางสถานประกอบการถาวรซึ่งมีอยู่ในอาณาเขตนั้นๆ บริษัทดังกล่าวเป็นวิสาหกิจของประเทศสวีเดน ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามความตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ข้อ 2(1) (ข) (4) ของความตกลงดังกล่าวกำหนดว่าบุคคลที่กระทำการในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่งเพื่อหรือแทนวิสาหกิจของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งให้ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรของวิสาหกิจนั้น ในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่แรก แต่ต้องมีเงื่อนไขว่า 1. ผู้นั้นมีและใช้อยู่เป็นปกติวิสัยในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่แรก ซึ่งอำนาจทั่วไปในการเจรจาและตกลงทำสัญญาต่าง ๆ เพื่อหรือแทนวิสาหกิจนั้น เว้นไว้แต่ว่าการดำเนินงานต่าง ๆ ของบุคคลนั้นจำกัดอยู่แต่เฉพาะเพียงการซื้อขายหรือสินค้าเพื่อวิสาหกิจนั้น ฯลฯ หรือ 3. ผู้นั้นจัดทำคำสั่งซื้อในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่แรกอย่างเป็นปกติวิสัยทั้งหมดหรือเกือบหมดเพื่อวิสาหกิจนั้นเอง หรือเพื่อวิสาหกิจและวิสาหกิจอื่นซึ่งวิสาหกิจนั้นควบคุมอยู่หรือมีผลประโยชน์ควบคุมอยู่ โจทก์มีนายมานะ พิทยาภรณ์และนายศิริชัย แสงกร หรือแสงสร เป็นพยานเบิกความยืนยันว่า โจทก์ไม่มีอำนาจทั่วไปในการเจรจาและตกลงทำสัญญาต่าง ๆ แทนบริษัทแอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด เป็นปกติวิสัยในประเทศไทยและโจทก์ไม่ได้เป็นตัวแทนผู้ทำการติดต่อ

เกี่ยวกับการซื้อขายแทนบริษัทดังกล่าวได้ความจากนายโอ ลอฟ มอเรนเดอร์ พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการใหญ่ของโจทก์ว่า ในการที่บริษัทดังกล่าวทำสัญญาขายอุปกรณ์โทรคมนาคมให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนั้น โจทก์ไม่เคยลงนามในสัญญาหรือต่อรองราคาแทนบริษัทดังกล่าวเลย ทั้งโจทก์ไม่มีอำนาจลงนามในสัญญาแทนบริษัทดังกล่าวด้วย ฝ่ายจำเลยมีนายจำรูญ วัชรากัยผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นมาเบิกความว่าในการที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซื้ออุปกรณ์เครื่องชุมสายโทรศัพท์จากบริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด นั้น โจทก์เคยมาติดต่อบริษัทสั่งซื้อไป แต่พยานปากนี้ก็เบิกความยอมรับว่าพยานไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับบริษัทดังกล่าว ได้ความจากนายชัยยศ หินทอง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร พยานจำเลยว่า จากการตรวจสอบพบว่าโจทก์เป็นตัวแทนของบริษัทดังกล่าว เมื่อกองตรวจภาษีอากรมีหนังสือเอกสารหมายเลข 9 ถึงองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับบริษัทดังกล่าวก็ได้รับคำตอบตามเอกสารหมายเลข 4 ในการตอบคำถามค้านของทนายโจทก์ นายชัยยศอ้างว่าที่ลงความเห็นที่โจทก์เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทดังกล่าว ก็เพราะโจทก์มีส่วนร่วมในการร่างสัญญาซื้อขายและการออกของจากท่าเรือตามพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบนั้น ยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์มีอำนาจทั่วไปในการเจรจาและตกลงทำสัญญาต่าง ๆ แทนบริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด เป็นปกติวิสัย หรือโจทก์จัดหาคำสั่งซื้ออย่างเป็นปกติวิสัยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเพื่อบริษัทดังกล่าว โจทก์จึงไม่เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลรัษฎากร บัญญัติให้จัดเก็บภาษีจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไว้ 3 กรณี คือ 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศกระทำกิจการในประเทศไทย หรือกระทำกิจการในที่อื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทย ให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทย (มาตรา 66) เว้นแต่กิจการขนส่งที่ทำผ่านประเทศต่าง ๆ ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของค่าโดยสารหรือค่าระวางแล้วแต่กรณี (มาตรา 67) 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่ได้ มีสำนักงานสาขาดำเนินกิจการในประเทศไทย แต่ถ้ามีลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศดังกล่าวประกอบกิจการในประเทศไทยกฎหมายกำหนดให้ลูกจ้าง ผู้ทำการแทนหรือทำการติดต่อมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการเสียภาษีเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรที่ได้ในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ) 3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศที่มีได้กระทำกิจการในประเทศไทยและถือไม่ได้ว่าประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามวิธีการและอัตราที่กฎหมายกำหนด(มาตรา 70) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีให้

กับรัฐบาลไทยอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ประเทศไทย
ทำกับประเทศถิ่นที่อยู่ของบริษัทต่างประเทศนั้นตั้งอยู่ เมื่อมีข้อตกลงว่าด้วย
อนุสัญญาภาษีซ้อนก็ต้องบังคับไปตามอนุสัญญาดังกล่าวเพราะมีผลบังคับเหนือ
ประมวลรัษฎากร ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้เป็นกรณี บริษัท แอลเอ็มอีริค
สัน จำกัด ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวีเดนหรือเรียกว่าบริษัทต่างประเทศซึ่งมี
ภาระจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยหรือไม่ต้องพิจารณาประมวลรัษฎากรมาตรา
67,76 ทวิ และ 70 แต่เมื่อปรากฏว่าประเทศไทยกับประเทศสวีเดนมีข้อตกลงว่า
ด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนจึงต้องพิจารณาความตกลงระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสวีเดน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2505 ซึ่ง
ตามข้อ 3(1) กำหนดว่า "กำไรของวิสาหกิจ" ของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่งให้เสียภาษี
เฉพาะแต่ในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายนั้นเท่านั้น เว้นไว้แต่ว่าวิสาหกิจนั้น
กระทำธุรกิจภายในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งโดยผ่านทางสถานประกอบการ
ถาวรซึ่งมีอยู่ภายในอาณาเขตนั้น..."หลักการสำคัญของอนุสัญญาภาษีซ้อนถือถิ่นที่
อยู่ของผู้มีเงินได้เป็นสำคัญไม่ว่าเงินได้จะเกิดขึ้น ณ ที่ใดจะต้องเสียภาษีให้กับ
ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ ประเทศเจ้าของแหล่งเงินได้หาสิทธิจัดเก็บภาษีไม่ เว้นแต่
บริษัทหรือวิสาหกิจต่างประเทศนั้นจะประกอบธุรกิจผ่านทางสถานประกอบการถาวร
ที่ตั้งอยู่ในประเทศแหล่งเงินได้ ประเทศเจ้าของแหล่งเงินได้จึงมีอำนาจจัดเก็บภาษี
ได้ ตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดน เพื่อการเว้นการเก็บภาษี
ซ้อน ข้อ 2(1)(ซ) ได้นิยามศัพท์คำว่า"สถานประกอบการถาวร" หมายความว่าสถาน
ธุรกิจประจำ ซึ่งวิสาหกิจใช้ประกอบธุรกิจทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (1) คำว่า "สถาน
ธุรกิจประจำ" ให้รวมถึง สถานจัดการ สาขาสำนักงาน โรงงาน โรงร้าน คลังสินค้า
เหมืองแร่ เหมืองหิน หรือสถานที่อื่นที่ใช้ในการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ (2)
วิสาหกิจของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่ง ให้ถือว่ามิใช่สถานธุรกิจประจำในอาณาเขตของ
รัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งถ้าหากว่าวิสาหกิจนั้นดำเนินการก่อสร้างติดตั้งหรือประกอบ

สินค้าขึ้นให้สำเร็จรูป หรือการอื่นคล้ายกัน ในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง นั้น (3) การใช้เพียงความสะดวกในการเก็บรักษาหรือการมีสถานที่ประกอบธุรกิจไว้ โดยเฉพาะเพื่อการซื้อสิ่งของหรือสินค้าและไม่ใช่เพื่อแปรรูปสิ่งของหรือสินค้าแต่อย่างใดในอาณาเขตที่ทำการซื้อเพียงเท่านั้นไม่ให้ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวร (4) บุคคลที่กระทำการในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่งเพื่อหรือแทนวิสาหกิจของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรของวิสาหกิจนั้นในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่แรก แต่ต้องมีเงื่อนไขว่า 1. ผู้นั้นมีและใช้อยู่เป็นปกติวิสัยในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่แรกซึ่งอำนาจทั่วไปในการเจรจา และตกลงทำสัญญาต่าง ๆ เพื่อหรือแทนวิสาหกิจนั้น เว้นไว้แต่การดำเนินงานต่าง ๆ ของบุคคลนั้น จำกัดอยู่แต่เฉพาะเพียงการซื้อสิ่งของหรือสินค้าเพื่อวิสาหกิจนั้น หรือ 2. ผู้นั้นได้เก็บรักษาอยู่เป็นปกติวิสัยซึ่งสต็อกสิ่งของหรือสินค้า ซึ่งเป็นของวิสาหกิจนั้นไว้ในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่แรก และดำเนินการส่งมอบสิ่งของหรือสินค้านั้นเพื่อหรือแทนวิสาหกิจนั้น หรือ 3. ผู้นั้นจัดหาคำสั่งซื้อในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่แรกอย่างเป็นปกติวิสัยทั้งหมดหรือเกือบหมด เพื่อวิสาหกิจนั้นเอง หรือเพื่อวิสาหกิจและวิสาหกิจอื่นซึ่งวิสาหกิจนั้นควบคุมอยู่ หรือมีผลประโยชน์ควบคุมอยู่ (5) นายหน้าที่มีฐานะเป็นอิสระอย่างแท้จริง ซึ่งดำเนินการแต่เพียงเป็นสื่อกลางระหว่างวิสาหกิจหนึ่งของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่งและผู้ที่จะเป็นลูกค้าในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งนั้น...ไม่ให้ถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรในอาณาเขตที่กล่าวถึงที่หลังของวิสาหกิจนั้น (6) ข้อเท็จจริงที่ว่า บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นผู้อยู่ในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่งมีบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้อยู่ในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งหรือดำเนินการค้าหรือธุรกิจในอาณาเขตของรัฐบาลอีกฝ่ายหนึ่งนั้น (ไม่ว่าโดยทางสถานประกอบการถาวรหรือทางอื่น) โดยข้อเท็จจริงเพียงเท่านั้น ไม่ถือว่าเป็นเหตุทำให้บริษัทย่อยเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทใหญ่" ลักษณะสำคัญของสถานประกอบการถาวร ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการคือ 1. ต้องมีสถานธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร สิ่งก่อสร้าง หรือ

สิ่งอื่นได้อันก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์แห่งการมีเงินได้². สถานธุรกิจต้องมีลักษณะประจำ โดยธรรมชาติควรจะมีลักษณะคงทนอยู่นานพอสมควรและมีการประกอบกิจการประจำหรือเป็นปกติวิสัยในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหาจำเป็นต้องประกอบกิจการเป็นประจำตลอดไป³. สถานธุรกิจต้องมีไว้เพื่อใช้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนกล่าวคือสถานธุรกิจได้ประกอบกิจการในรัฐหนึ่งเพื่อวิสาหกิจในต่างประเทศเพียงแห่งเดียวมิได้ดำเนินการให้วิสาหกิจอื่นใดอีก หรือดำเนินธุรกิจเพื่อวิสาหกิจนั้นเองบางส่วนและเพื่อผู้อื่นบางส่วนด้วยก็ถือเป็นสถานประกอบการถาวรเช่นกัน ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจในประเทศหนึ่งจะเข้าข่ายเป็นสถานประกอบการถาวร นอกจากต้องมียอดประกอบครบ 3 กรณีดังกล่าวมาแล้ว สถานประกอบการถาวรยังอาจแยกได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. สถานประกอบการถาวรประเภททรัพย์สิน (Asset) ทรัพย์สินที่มีลักษณะตรึงตราติดแน่นอยู่ที่จุดหนึ่งจุดใดในทางภูมิศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น สถานจัดการ สาขา สำนักงาน โรงงานโรงงาน คลังสินค้า เหมืองแร่ เหมืองหิน บ่อน้ำมัน บ่อก๊าซสถานขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติ ที่ทำการเพาะปลูก สถานที่เลี้ยงสัตว์หรือไร่ สวน สถานที่ขายของ ที่ตั้งอาคาร โครงการก่อสร้าง โครงการติดตั้งหรือโครงการประกอบ ซึ่งดำเนินติดต่อกัน (สำหรับระยะเวลาแล้วแต่ประเทศคู่สัญญาจะกำหนด) การประกอบธุรกิจผ่านทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแต่กิจกรรมที่ดำเนินการนั้นต้องเป็นไปโดยสม่ำเสมอแม้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มีข้อสังเกตว่าทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าเมื่อวิสาหกิจให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์โดยคิดค่าตอบแทนผ่านสถานธุรกิจประจำของรัฐผู้ทำสัญญาอีกรัฐหนึ่ง โดยทั่วไปถือว่าวิสาหกิจดังกล่าวมีเงินได้เกิดขึ้นผ่านสถานประกอบการถาวรต้องเสียภาษีให้ประเทศเจ้าของแหล่งเงินได้ 2. สถานประกอบการถาวรประเภทตัวแทน (Agent) ตัวแทนที่จะถือว่าเป็นสถานประกอบการถาวรจะต้องมีสถานภาพไม่อิสระ คือจะต้องทำตามข้อผูกมัดกับวิสาหกิจซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศเพียงแห่งเดียว มีอำนาจในการ

เจรจาทำสัญญา การส่งมอบสินค้าหรือปฏิบัติตามคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นปกติวิสัย ส่วนตัวแทนที่อิสระจากวิสาหกิจต่างประเทศมีความเป็นอิสระทั้งในด้านกฎหมายและเศรษฐกิจ โดยประกอบธุรกิจเป็นปกติธุระของตนเอง ไม่มีสัญญาผูกพันใด ๆ กับวิสาหกิจต่างประเทศ แต่ถ้าตัวแทนอิสระดังกล่าวกระทำเพื่อวิสาหกิจต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งมีมากผิดปกติในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ สภาพความเป็นอิสระจะหมดไปกลายเป็นสถานประกอบการถาวรของวิสาหกิจต่างประเทศนั้น ๆ ไป 3.

สถานประกอบการถาวรประเภทกิจกรรม (Activities) เป็นกรณีที่วิสาหกิจของรัฐบาลคู่ภาคีฝ่ายหนึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในอาณาเขตของรัฐบาลคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น กิจกรรมตรวจสอบควบคุมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ การให้บริการบางอย่างที่ต้องอาศัยวิชาความรู้เฉพาะด้าน การให้คำปรึกษาแนะนำโดยผ่านทางลูกจ้างหรือบุคคลอื่น สำหรับโครงการเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน การบริการของนักแสดงสาธารณะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะต้องดำเนินติดต่อกันเป็นช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งสำหรับระยะเวลานั้นจะต้องตกลงกันให้แน่ชัดจึงจะถือเป็นสถานประกอบการถาวรได้คณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์ของกรมสรรพากรได้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2528 ว่า "...กรณีที่บริษัทสวีเดนผู้ขายเครื่องจักรดังกล่าวส่งวิศวกรเข้ามาควบคุมให้คำแนะนำในการติดตั้งเครื่องจักรรวมทั้งฝึกสอนพนักงานของผู้ซื้อ และดำเนินการทดลองเดินเครื่องจักรโดยคิดค่าบริการเป็นเงิน SEK2,780,000.- นั้น เข้าลักษณะเป็นกรณีที่บริษัทสวีเดนผู้ขายมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยตามข้อ 2(1)(ข)(2) แห่งความตกลงดังกล่าว ฉะนั้นบริษัทผู้ขายจึงต้องนำเงินได้เฉพาะค่าบริการจำนวน SEK2,780,000.- มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 76 ทวิ และเมื่อจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทยต้องเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรด้วย ทั้งนี้ตามนัยข้อ 3 วรรคหนึ่งแห่งความตกลงดังกล่าว..." ประเด็นสำคัญในคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้มีว่าบริษัทอีริคสันเทเลโฟนคอปอเรชั่นฟาร์อีสท์ จำกัด โจทก์เป็นตัวแทน(Agent) ของบริษัท แอลเอ็มอีริคสัน

จำกัด อันจะถือเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัท แอลเอ็มอีริคสัน จำกัด หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่สถานประกอบการถาวรของบริษัท แอลเอ็มอีริคสัน จำกัด เพราะโจทก์ไม่มีอำนาจทั่วไปในการเจรจาและตกลงทำสัญญาต่าง ๆ แทน บริษัท แอลเอ็มอีริคสัน จำกัด เป็นปกติวิสัยหรือจัดหาคำสั่งซื้ออย่างเป็นปกติวิสัย ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเพื่อบริษัทแอลเอ็มอีริคสัน จำกัด ตามความตกลงระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศสวีเดน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ข้อ 2(1)(ซ)(4)1,3 ผู้ บันทึกเห็นว่าหลักที่ศาลฎีกานำมาวินิจฉัยว่าโจทก์มิใช่สถานประกอบการถาวรของ บริษัทต่างประเทศ คือ 1. หลักความเป็นอิสระ โจทก์มิได้อยู่ในอาณัติหรือข้อผูกพัน ใด ๆ กับบริษัท แอลเอ็มอีริคสัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทต่างประเทศ เพื่อประกอบธุรกิจ อันมีเงินได้ให้กับบริษัทต่างประเทศดังกล่าว อันจะทำให้โจทก์ขาดความเป็นอิสระไป ผู้บันทึกเห็นว่าจะต้องพิจารณาประเภทของธุรกิจที่ประกอบด้วย ถ้าหากขาดความ เป็นอิสระเฉพาะธุรกิจประเภทที่มีการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศแล้ว เฉพาะธุรกิจ ประเภทนั้น ๆ ย่อมถือเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทต่างประเทศในธุรกิจ ประเภทนั้น ๆ ได้ 2. หลักความเป็นปกติวิสัย (Habit) ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มี อำนาจทั่วไปในการเจรจาและตกลงทำสัญญาต่าง ๆ แทนบริษัทแอลเอ็มอีริคสัน จำกัด เป็นปกติวิสัยหรือจัดหาคำสั่งซื้ออย่างเป็นปกติวิสัยทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เพื่อบริษัท แอลเอ็มอีริคสัน จำกัด ผู้บันทึกเห็นว่าการที่บุคคลใดหรือนิติบุคคลใด กระทำธุรกิจก่อให้เกิดเงินได้เพื่อบริษัทต่างประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นปกติวิสัย บุคคลนั้นหรือนิติบุคคลนั้นย่อมขาดความเป็นอิสระในกิจการประเภทนั้น ๆ แม้ความ จริงจะมีได้มีสัญญาข้อผูกพันกันทางกฎหมายแต่มีลักษณะผูกพันกันทางธุรกิจย่อม ถือเป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัทต่างประเทศได้ ปัญหาคงมีว่า คำว่า "ปกติ วิสัย" จะต้องมีความถี่แห่งกิจกรรมนั้น ๆ มากน้อยเพียงไร ผู้บันทึกเห็นว่าน่าจะต้อง พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป สมมุติว่าบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยทำการติดต่อ ขยายสินค้าจำพวกยุทธปัจจัยที่ใช้ในราชการสงครามให้กับกองทัพบกจนเกิดเงินได้กับ

บริษัทต่างประเทศปีละครั้งตามงบประมาณของทางราชการและมีการติดต่อกันทุกปี เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เพียงเท่านี้ผู้บันทึกเห็นว่าเป็นปกติวิสัยแล้ว เพราะ ประเภทธุรกิจถูกบังคับด้วยเงินงบประมาณและลักษณะของสินค้าที่ทำการซื้อขายกัน ดังนั้นการที่จะพิจารณาว่าบุคคลหรือนิติบุคคลจะเป็นสถานประกอบการถาวรของ บริษัทต่างประเทศหรือไม่ จำต้องสืบให้ปรากฏชัดถึงประเภทของธุรกิจและลักษณะ ธรรมชาติของธุรกิจประเภทนั้น ๆ ตลอดทั้งธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติก่อน ๆ หรือนั้นขึ้นไปเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจด้วย วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล